

1500414-04.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... fatos, realizando investigação de tráfico de drogas no local, já conhecido como ponto de trafico. Disse que estava em viatura descaracterizada e viu nitidamente o acusado sentado em uma mesa , tendo ele , em dado momento, se levantado, atendido uma pessoa que dele se aproximou de bicicleta. Em seguida , o acusado pegou algo homiziado atrás de uma árvore e entregou ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500414-04.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/000338

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079690/2022 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 23795640 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 27/22/594 - GOE-DEIC-DEINTER 9, 2079690 - GOE-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTONIO VIEIRA NETO

Aos 08 de setembro de 2022, às 15:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: LUIZ ANTONIO VIEIRA NETO - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO BARHUN - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC ROGERIO JOSE DA SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foi colhido o depoimento da testemunha testemunhas PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CAMARGO BARHUN.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, por ela foi dito que desistia da oitiva

da testemunha PC ROGERIO JOSE DA SILVA, o que foi homologado pela MM^a. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PC ROGERIO JOSE DA SILVA, o que foi homologado pela MM^a. Juíza.

Após, o réu LUIZ ANTONIO VIEIRA NETO foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "LUIZ ANTÔNIO VIEIRA NETO, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 60/62. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 73), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 77/81), sendo a denúncia recebida (fls. 82/84). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva do tráfico de entorpecentes está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, fotografia de fls. 13 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 51/53. A autoria é incontroversa. O policial civil Marcio Luiz Teixeira de Camargo Barhun, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, no dia dos fatos, realizando investigação de tráfico de drogas no local, já conhecido como ponto de trafico. Disse que estava em viatura descaracterizada e viu nitidamente o acusado sentado em uma mesa, tendo ele, em dado momento, se levantado, atendido uma pessoa que dele se aproximou de bicicleta. Em seguida, o acusado pegou algo homiziado atrás de uma árvore e entregou ao interlocutor, recebendo dinheiro em contrapartida. Na sequência, o acusado devolveu algo atrás da referida árvore. Disse que em seguida a conduta se repetiu com outra pessoa, que se aproximou do acusado, manteve com este contato e, em seguida, o réu foi novamente até a árvore. Diante disto, a testemunha entrou em contato com o policial Rogério e transmitiu as características físicas, de vestimenta e o local onde o acusado se encontrava. Rogério localizou o réu no local dos fatos, em revista pessoal com ele nada de ilícito fora encontrado, realizando busca na árvore citada localizou onze porções de de cocaína, sendo o acusado preso em flagrante delito. No mesmo sentido foram as palavras do policial civil Rogério José da Silva, ouvido apenas na fase policial.. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que as drogas apreendidas eram de sua propriedade, porém eram destinadas ao seu uso. Disse que havia escondido as porções de cocaína embaixo da árvore para não ficarem no seu bolso e, toda vez que ia usar, ia até a árvore e pegava uma porção. Negou, outrossim, ter mantido contato com outras pessoas. Assim, em que pese a negativa do réu quanto aos fatos, sua versão não deve prevalecer, vez que dissonante e isolada das demais provas coligidas nos autos, não encontrando nelas qualquer respaldo. De fato, é certo que o policial civil ouvido foi categórico ao afirmar que viu o acusado mantendo contato com outras pessoas, que o procuravam, lhe entregavam dinheiro e ele então ia até a árvore, pegava as drogas e as entregava ao referido indivíduo. Outrossim, não é crível a alegação do acusado de que guardaria drogas para seu próprio uso escondidas em uma árvore, e que iria até o local apenas para pegar a porção de droga quando fosse usa-la. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em

juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime de tráfico descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, tem-se que o réu é tecnicamente primário. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, presentes os requisitos legais, cabível o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Excelência, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Marcio, Policial Civil, declarou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico. A testemunha ficou observando a movimentação do local e viu quando o réu fez a venda para uma pessoa de bicicleta. Viu que ele foi até uma árvore, pegou um objeto, entregou para essa pessoa e recebeu algo em troca. Depois ele foi até um bar e voltou, sentando-se em uma mesa. Essa situação se repetiu mais uma vez e a testemunha acionou os demais colegas para abordarem o acusado. Eles abordaram o réu e nada de ilícito foi localizado com ele. Posteriormente, no local onde o acusado mexia, encontraram as drogas descritas na denúncia. O réu, em interrogatório, declarou que as drogas lhe pertenciam, mas se destinavam ao seu consumo pessoal. Pegou dinheiro com sua irmã e comprou as substâncias, deixando-as escondidas na árvore enquanto usava os entorpecentes. Estava usando as drogas desde o dia anterior, porém, a única pessoa com quem manteve contato foi seu amigo, com quem estava usando entorpecentes conjuntamente. Não portava dinheiro. Foi até o bar e comprou um litro de cerveja. Deixou as drogas na árvore para não ficar portando os entorpecentes, pois sabe que são substâncias ilícitas. Cada vez que precisava, ia ao local e pegava uma porção. Portanto, o acusado nega a prática do tráfico de drogas e esclarece que as porções encontradas se destinavam a seu consumo pessoal. No mais, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem, em juízo, a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras dos Policiais como fundamento para uma condenação, verbis: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela

insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais e da "movimentação suspeita" visualizada, não é possível afirmar, com certeza, que os atos descritos na denúncia se tratavam de atos de comércio, eis que os supostos compradores não foram apresentados na Delegacia de Polícia como testemunhas presenciais das diligências. Além disso, a afirmação de que o local dos fatos se tratava de um "ponto de tráfico" não é, por si só, motivo para a procedência da ação penal, haja vista que, nesses locais, circulam tanto pessoas que se dedicam ao comércio de drogas como usuários dessas substâncias. Ressalte-se, também, que, no caso concreto, as drogas não estavam sob a posse direta do acusado, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. E, se o réu tivesse efetivamente mantido contato com supostos compradores, ele teria, por consequência, dinheiro em seu poder, o que não ocorreu. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Dessa forma, ante a manifesta insuficiência probatória, a absolvição é medida de rigor, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo reconhecer que apenas as drogas encontradas em poder do réu lhe pertenciam, afastando-se a propriedade das demais substâncias, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Acaso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. É que, na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado, à época dos fatos, era tecnicamente primário. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido apenas em função da quantidade de entorpecentes que fora apreendida, que, aliás, nem mesmo se mostra elevada, na hipótese. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra "dedicação às atividades criminosas", faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu. Além disto, o Decreto 5.015/04, que promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, define, em seu artigo 2º, o conceito de organização criminosa: "Artigo 2º - Terminologia. Para efeitos da presente Convenção, entende-se por: a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou

enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material; (...). Do cotejo do texto legal acima citado, é evidente que não se configurou uma organização criminosa. Assim, quanto a “integrar organização criminosa”, é possível afirmar que a intenção do legislador foi vedar a aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo àquele que é membro de organização criminosa, ou seja, possui vínculo de forma ativa e permanente com a mesma, além de grande envolvimento com seus mecanismos e pessoas, o que, à evidência, não ocorre na hipótese em testilha. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida)” (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, e que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao réu, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase; (ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, com as substituições que se mostrarem cabíveis, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ, observando-se, também, o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista que ele respondeu solto a este processo e inexistente fato concreto que, justifique, neste momento, a decretação de sua prisão preventiva”.

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:
" Vistos.

LUIZ ANTONIO VIEIRA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de março de 2022, por volta das 10h, na Avenida Lourenço, nº 100, esquina com a Alameda Frei Liberato de Gries, bairro Cecap, nesta cidade e comarca de Piracicaba, tinha em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 11 (onze) porções de cocaína em pó, com peso líquido de 1,5g (um grama e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Narra a denúncia que policiais civis realizavam campanha pelo local dos fatos, já conhecido ponto de venda de drogas, quando visualizaram o réu em atividade típica de tráfico, eis que manteve contato com diversas pessoas, pegando algo homiziado atrás de uma árvore, entregando aos interlocutores e recebendo dinheiro deles em contrapartida. Em razão disso, os investigadores procederam à abordagem do réu e nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Ato contínuo, os policiais diligenciaram na árvore onde o réu mexia anteriormente e localizaram onze porções

de cocaína em pó.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 73) e apresentou defesa preliminar (fls. 77/81). Após, a decisão de fls. 82/84 recebeu a denúncia. Designada audiência, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pela fotografia de fls. 13, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 51/53, que trouxe resultado positivo para cocaína, e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, negou a prática do crime. Asseverou que a draga apreendida lhe pertencia, mas era para fins de uso, não de tráfico. Afirmou que estava no bar e tinha deixado a droga guardada na árvore para usar. Alegou que ficou o dia todo usando drogas e, quando queria, ia até a árvore, pegava uma porção e usava. Declarou que não manteve contato com pessoas que chegavam ao local de bicicleta, só com um colega seu, que estava usando droga com ele. Atestou que não tinha nenhum dinheiro em seu poder e, se estivesse traficando, estaria com dinheiro.

A negativa, porém, foi infirmada pela prova produzida.

O policial civil Márcio Luiz relatou que estava fazendo investigação em local já conhecido como ponto de tráfico e ficou observando a movimentação. Atestou que notou o réu, que fez venda para um rapaz que estava numa bicicleta. Disse que ele foi até a árvore, pegou algo, entregou para o rapaz, recebeu algo em troca e, na sequência, foi até o bar, comprou alguma coisa e voltou a se sentar na mesa, na praça. Afirmou que, depois, apareceu outra pessoa e o réu procedeu da mesma forma. Então, acionou a equipe e o réu foi abordado. Disse que, com ele, nada foi encontrado, mas, na árvore que ele acessou, localizaram onze porções de cocaína. No mesmo sentido o depoimento do policial Rogério, ouvido a fls. 03.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). Logo, não é sequer razoável supor que policiais atestariam que flagraram o acusado traficando, se isso não fosse, efetivamente, o que presenciaram.

Enfim, o fato de os policiais terem visualizado o acusado no local, em atividades típicas da traficância, pegando objetos atrás de uma árvore, entregando para uma pessoa que se aproximava dele de bicicleta e recebendo algo em troca, por diversas vezes, vindo, logo em seguida, a abordá-lo e a localizar onze porções de cocaína escondidas atrás da árvore, conduz à certeza quanto a autoria e a destinação da droga ao comércio ilícito.

Anoto que a quantidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, e às circunstâncias da apreensão evidenciam mesmo a destinação ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido.” (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Ademais, como bem anotou a d. Promotora de Justiça em suas alegações finais, “não é crível a alegação do acusado de que guardaria drogas para seu próprio uso escondidas em uma árvore, e que iria até o local apenas para pegar a porção de droga quando fosse usá-la”.

Consigno que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Importa anotar, ainda, que os policiais atestaram que o réu confessou informalmente a traficância, revelando, inclusive, detalhes da movimentação do crime, bem como que repassava o dinheiro a outro indivíduo que passava pelo local.

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena-base no mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

Não há causas de aumento. De outro lado, o réu não tem antecedentes criminais e não há indícios de seu envolvimento com o crime organizado. Assim, reduzo a pena fixada em dois terços, nos termos do art. 33, § 4º, e 42, ambos da Lei nº 11.343/06, totalizando um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto à substituição da pena corporal por restritiva de direito, muito embora, em tese, possível, comungo do entendimento de que a benesse é incompatível ao condenado por crime de tráfico, não em função de impeditivo legal, mas pela periculosidade social presumida, incompatibilizando o autor de delito dessa natureza com atividades comunitárias ou assistenciais, na medida em que o recoloca em contato direto com grupo suscetível ao seu assédio (cf. Apelação nº 0004555-80.2014.8.26.0451, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 26.01.17).

Observo que o art. 44 do Código Penal, em seu inciso III, expõe elementos a serem considerados quando da substituição da pena corporal por restritiva de direito, consignando, ao final, a necessidade de que a substituição seja “suficiente”.

Na hipótese, a substituição é medida insuficiente para a prevenção do abjeto comércio que se difunde e fomenta a delinquência no país, sendo, portanto, de

acordo com a regra prevista no inciso III do referido diploma penal, imperiosa a manutenção da pena privativa de liberdade.

No que tange à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, consigno que, com a edição do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão do disposto pelo art. 3º do Código de Processo Penal, estabeleceu-se a necessidade de os juízes observarem o precedente ao julgar determinada matéria.

Com efeito, o art. 926 do Código de Processo Civil dispõe: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente."

Já o art. 927 do mesmo código estatui: "Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados."

Prosseguindo, o art. 928 estabelece: "Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I - incidente de resolução de demandas repetitivas; II - recursos especial e extraordinário repetitivos".

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, firmou entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda.

Nesse contexto, anotou a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no julgamento do Recurso Especial paradigma 1.329.088/RS, referente ao Tema 600 do Superior Tribunal de Justiça: "É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a proliferação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalícia, sob o rito dos recursos repetitivos".

E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em 2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Enfim, estando pacificada nas Cortes Superiores a não hediondez do tráfico privilegiado, sendo o réu primário e imposta pena inferior a quatro anos, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu LUIZ ANTONIO VIEIRA NETO, qualificado nos autos, por incurso no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial aberto.

Oportunamente, expeça-se mandado de prisão a ser cumprido em regime aberto, e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data.

.

- 2) Tendo em vista a fixação de regime aberto para cumprimento da pena, expeça-se termo de advertência em apartado concomitantemente com mandado de prisão de regime aberto.
- 3) Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD, SARC e TRE.
- 4) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.
- 5) Tratando-se de multa cumulativamente aplicada, providencie-se inserção do valor atualizado no sistema informatizado, consignando-se o montante de R\$6.933,75, equivalente a 216,88 UFESPs, oportunamente abrindo-se vista ao Ministério Público para as providências cabíveis.
- 6) O réu foi assistido por Defensor Público, logo, está isento das custas processuais.
- 7) Regularizados os autos, archive-se com a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", nos termos do Art. 480, §1º, das NSCGJ. Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]